

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

nr. 235.523 van 18 juli 2016
in de zaak A. 219.569/XII-8177

In zake: 1. de NV BAM CONTRACTORS
 2. de NV GALERE
 samen vormend het NBCC Consortium
 bijgestaan en vertegenwoordigd door
 advocaat Bob Martens
 kantoor houdend te 1050 Brussel
 Louizalaan 106
 bij wie woonplaats wordt gekozen

 tegen:

 de CVBA NEO
 bijgestaan en vertegenwoordigd door
 advocaat France Vlassembrouck
 kantoor houdend te 1200 Brussel
 Neerveldstraat 101-103
 bij wie woonplaats wordt gekozen
 eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door
 advocaat Rika Heijse

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 24 juni 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing [van de raad van bestuur van de cvba NEO van] 7 juni 2016 tot het onregelmatig verklaren van het Tweede Voorstel [van consortium A] en het definitief uitsluiten [van consortium A] van de concurrentiegerichte dialoog met betrekking tot de gunning van de overheidsopdracht voor werken ‘NEO tweede schijf – Congrescentrum en hotel(s) op het Heizelplateau’”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 12 juli 2016, om 14.30 uur.

Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Bob Martens en Jorren Garrez, die verschijnen voor de verzoekende partijen, advocaat Isabelle Kamp, *loco* advocaat France Vlassembrouck, en advocaat Rika Heijse, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De stad Brussel schrijft een overheidsopdracht uit met als voorwerp “NEO – tweede schrijf Congrescentrum en Hotel op het Heizelplateau”. Het betreft een samengevoegde opdracht van de stad Brussel, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de op te richten – bij ordonnantie van 27 februari 2014 – projectmaatschappij NEO. De opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 30 juli 2013 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 3 augustus 2013.

In het kader van deze opdracht overweegt de aanbestedende dienst op het Heizelplateau de inrichting van een congrescentrum voor internationale vergaderingen tot 5.000 personen en met een groot auditorium van minstens 3.500 plaatsen en een hotel van hoge standing.

Geopteerd wordt om te gunnen bij wijze van de concurrentiegerichte dialoog.

3.2. Op 2 december 2013 melden zich vier kandidaten, onder wie Groepering “Neo Brussels Convention Centre” (afgekort NBCC), bestaande uit nv CEI-De Meyer en nv Galère, met ondersteuning van nv Koninklijke BAM Groep, BAM Deutschland AG, Office for Metropolitan Architecture Stedebouw bv, DDS & Partners Architects SC srl en nv SVR-Architects.

Op 7 februari 2014 vraagt de aanbestedende overheid aan deze kandidaat bijkomende informatie, inzonderheid inzake de derde entiteiten waarvan de financiële en economische draagkracht werd ingeroepen om de selectie te rechtvaardigen.

Verzoeksters antwoorden op dit verzoek tot bijkomende informatie door middel van twee e-mails op 4 maart 2014.

3.3. Bij goedkeuring van haar raad van bestuur van 14 juli 2014 heeft de verwerende partij de functie opgenomen van aanbestedende overheid en handelt zij vervolgens in eigen naam en in naam van en voor rekening van de stad Brussel en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

3.4. Na het nemen van de beslissing betreffende de kwalitatieve selectie, eveneens goedgekeurd door de raad van bestuur van 14 juli 2014, worden drie kandidaten, onder wie verzoeksters, geselecteerd om deel te nemen aan de dialoog en uitgenodigd om hun eerste voorstellen in te dienen.

Over de kandidatuur van verzoeksters wordt onder meer overwogen “dat de kandidaat (door zich te beroepen op de draagkracht van Koninklijke BAM Groep NV, dat zich er in de kandidatuur ingediend op 2 december 2013 toe heeft verbonden zijn middelen ter beschikking te stellen van het kandidaat-consortium voor de uitvoering van de opdracht in toepassing van artikel 74 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011) ten volle voldoet aan de minimale vereisten die in de aankondiging van de opdracht worden geformuleerd inzake economische en financiële draagkracht”.

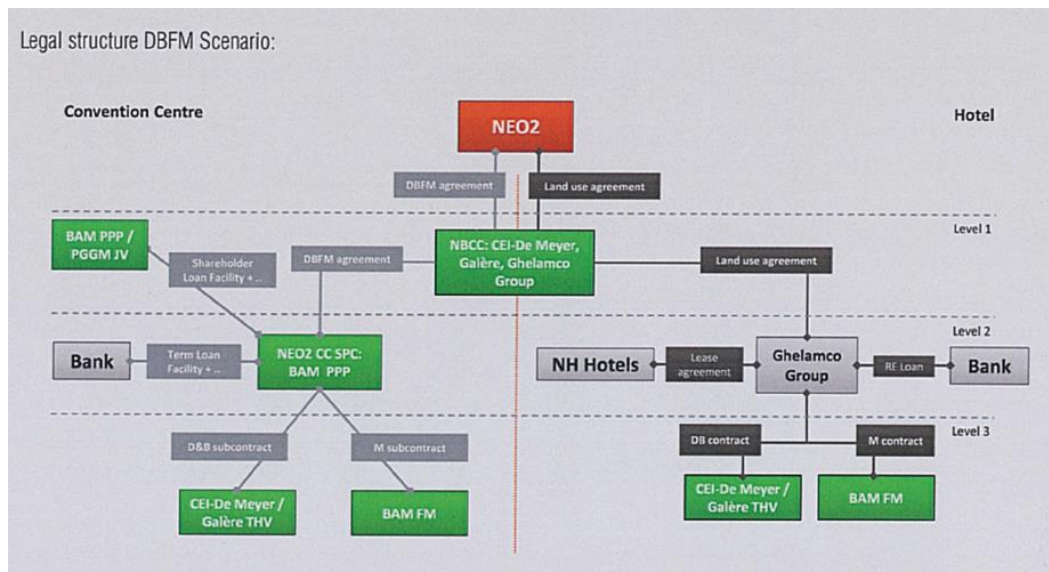
3.5. Bij dezelfde goedkeuringsbeslissing van 14 juli 2014, heeft de raad van bestuur van de verwerende partij tevens het beschrijvend document aangenomen, bestaande uit de dialooggids, de beschrijvende fiches en de *Design Brief*, met als doel de eerste fase van de dialoog met de drie geselecteerde deelnemers te organiseren.

3.6. De concurrentiegerichtte dialoog wordt gevoerd aan de hand van een zogenaamde ‘gefaseerde’ dialoog: de dialoogprocedure verloopt in minstens twee dialoofases.

3.7. Verzoeksters worden op 25 juli 2014 uitgenodigd om een eerste voorstel in te dienen. Zij ontvangen het beschrijvend document.

Een zitting voor vraag-en-antwoord wordt gehouden op 20 oktober 2014. Bovendien stellen de deelnemers schriftelijke vragen met betrekking tot de documenten van de opdracht. De verwerende partij antwoordt op deze vragen en het geheel van de antwoorden wordt aan alle deelnemers verstrekt.

Op 31 maart 2015 dienen verzoeksters hun eerste voorstel in. Dit eerste voorstel voorziet in de volgende contractuele structuur in geval van scenario DBFM:



3.8. Op 17 september 2015 stuurt de verwerende partij aan verzoeksters een brief met volgende vragen:

“2. Opmerkingen en vragen naar aanleiding van het voorstel [...]

Onderneming[:] Gelieve de rechtsvorm van het congrescentrum en Hotel SPV te verduidelijken.

Aansprakelijkheid[:] Gelieve uit te leggen wat dient te worden verstaan onder de volgende zin: ‘Ring Fence congrescentrum en hotel beide financieel en juridisch’ en aan te tonen hoe dit verenigbaar is met de voorziene verbintenissen in de aankondiging en in punt I.13 van de Dialooggids

Onderneming[:] Bij de Financial Close, verstaan we dat een DBFM entiteit (NEO2 CC SPV) zal worden opgericht in de vorm van een NV/SA. 100% van de aandelen van dergelijke entiteit zullen in handen zijn van een andere onderneming, waarnaar verwezen als ‘sponsor’.

Gelieve te bevestigen of een meerderheid van deze aandelen uitgegeven door NEO2 CC SPV zullen in handen zijn van een derde partij sponsor? Indien ja, gelieve bijkomende informatie te bezorgen met betrekking tot de potentiële sponsor. Gelieve alsook te bevestigen dat – ongeacht de bovenvermelde sponsor – het consortium hoofdelijk aansprakelijk blijft ten aanzien van de overheid (d.i.: de aanbestedende overheid)

We brengen in herinnering dat een van de hoofdpunten met betrekking tot NEO 2 Project is dat het consortium hoofdelijk aansprakelijk blijft ten aanzien van de overheid. Als 100 % van de aandelen van SPV1 gehouden worden door een andere partij dan het consortium, is het onduidelijk of de overheid kan blijven een voordeel halen uit de hoofdelijke aansprakelijkheidsmechanisme zoals voorzien onder punt I.13 van de Dialooggids

[...]

Aansprakelijkheid[:] In sectie 1.B Hotel (p. 105) van het Document, gelieve te verduidelijken wat bedoeld wordt met de volgende zin:

‘alle verantwoordelijkheden worden gedelegeerd aan de partner/vennoot die gezien zijn expertise en vaardigheden het best geplaatst is om de relevante delen van het project te bezorgen en om te gaan met de bijhorende uitdagingen en risico’s’.

Gelieve een voorbeeld te geven van de reikwijdte van deze verantwoordelijkheden die worden gedelegeerd en aan te tonen dat deze delegatie verenigbaar is met punt I.13. van de Dialooggids

[...]

Aansprakelijkheid[:] Om elke onduidelijkheid te vermijden, betekent het Ring Fencing principe dat NEO geen verhaal heeft wat betreft het Hotel tegen enige andere partij dan de ‘Real Estate Investor’ (veronderstellende dat deze Real Estate Investor handelt als een derde partij van het consortium)? Heeft het Ring Fence principe een impact op het feit dat ‘SPV1’ de volledige verantwoordelijkheid zal dragen om het project af te leveren conform de verwachtingen van NEO? Is dit verenigbaar met punt I.13 van de Dialooggids.”

3.9. Op 19 oktober 2015 stelt de raad van bestuur van de verwerende partij vast, onder meer, dat niet onwrikbaar kan worden besloten dat de voorgestelde projecten niet zouden voldoen aan de minimale vereisten die het beschrijvend document formuleert; hij oordeelt dat het aangewezen lijkt om bij het einde van de eerste dialoogfase niet over te gaan tot de verwijdering van bepaalde voorstellen en bijgevolg de deelnemers te verzoeken tweede voorstellen in te dienen die voorzien in een verfijning, een verbetering of een wijziging van hun eerste voorstellen.

Op 21 oktober 2015 deelt de verwerende partij aan de drie deelnemers de oriënteringsgids en haar bijlagen mee die, overeenkomstig de dialooggids, het kader vormen voor de tweede fase van de dialoog, evenals de specifieke individuele oriëntaties aan elk van de deelnemers, met het oog op ophelderingen, verduidelijkingen, verdiepingen en de herziening of verbetering van de verschillende aspecten van hun eerste voorstel.

3.10. In de individuele oriëntaties geadresseerd aan verzoeksters vraagt de verwerende partij hen om bepaalde elementen van hun contractuele structuur te verduidelijken, in het bijzonder om zich ervan te vergewissen dat de

‡BIHQKDGDJ-BCGAHAV‡

‘ring-fencing’ van het congrescentrum en het hotel de hoofdelijkheid van de leden van het consortium niet in het gedrang zou brengen:

- de verbintenissen van de vennootschap “Koninklijke Bam Groep nv” verduidelijken met betrekking tot het consortium in het licht van de realisatie van het project, aangezien de economische en financiële draagkracht van de vennootschap noodzakelijk is voor het behoud van de naleving van de kwalitatieve selectiecriteria door de deelnemer;
- de verbintenissen van de vennootschap “Bam Deutschland AG” verduidelijken met betrekking tot het consortium in het licht van de realisatie van het project, aangezien het de vakbekwaamheid noodzakelijk is voor het behoud van de naleving van de kwalitatieve selectiecriteria door de deelnemer en waarin deze vennootschap niet vermeld is in het dossier en de begeleidende brief bij het eerste voorstel; er wordt in dit verband verwezen naar artikel I.II van de dialooggids;
- bevestigen dat de “Congrescentrum & Hotel SPV”, de “Congrescentrum SPV” en de “Hotel SPV” naamloze vennootschappen naar Belgisch recht zijn;
- bevestigen tot welke limiet (in %) elk lid van de deelnemer een deelneming neemt in de “Congrescentrum & Hotel SPV” en de “Congrescentrum SPV”;
- indien het niet de Vastgoed Investeerder is die de enige eigenaar is van de “Hotel SPV” vanaf haar oprichting, bevestigen tot welke limiet (in %) elk lid van de deelnemer een deelneming neemt in de “Hotel SPV” en vanaf welk ogenblik de aandelen in de “Hotel SPV” kunnen worden overgedragen aan de vastgoedinvesteerder;
- verduidelijken wat de precieze draagwijdte is van de hoofdelijkheid voorzien in punt I.13 van de dialooggids en punt I.8 van de oriënteringsgids en welke vorm zij aanneemt;
- bevestigen dat het principe van “Ring-fencing” dat voorkomt op p. 107 van het document “Book 2 Financial” van het eerste voorstel, geen invloed heeft op de voormelde hoofdelijkheid waartoe de leden van de deelnemer zich hebben verbonden zoals voorzien in punt I.13 van de dialooggids en punt I.8 van de oriënteringsgids.

3.11. Ten gevolge van de voorbereidende gesprekken en vergaderingen en de geschreven vragen van de deelnemers naar aanleiding van of na deze vergaderingen, bezorgt de verwerende partij aan de drie deelnemers op geanonimiseerde wijze de antwoorden op hun vragen omtrent de opdrachtdocumenten. Meerdere vragen peilen naar de aard en de invulling van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelnemer en de projectvennootschappen.

3.12. Op 19 januari 2016 keurt de raad van bestuur van de verwerende partij sommige wijzigingen goed die aangebracht zijn aan de documenten van de tweede dialoogfase ingevolge de vraag- en antwoordronde met de drie deelnemers en de aanvullende opdrachtdocumenten die nodig zijn gebleken om de verwachtingen van de aanbestedende overheid te begrijpen in het kader van dezelfde procedure.

3.13. De nv BAM Contractors (voorheen nv CEI-De Meyer) en de nv Galère hebben vervolgens een tweede voorstel ingediend. De contractuele structuur die is opgenomen in dit tweede voorstel verschilt van het eerste voorstel.

De medecontractant van de verwerende partij zal niet langer de SPV1 zijn, samengesteld uit nv BAM Contractors, nv Galère en Ghelamco Group. Deze projectvennootschap, in het eerste voorstel op niveau 1 ('level 1') gesitueerd, wordt geschrapt. De medecontractanten van de verwerende partij zullen voortaan twee projectvennootschappen zijn: de SPV belast met het congrescentrum en de SPV belast met het hotel.

Het aandeelhouderschap in de twee projectvennootschappen wordt door verzoeksters in het tweede voorstel nader toegelicht. Hieruit blijkt dat in de fase van de uitvoering nv BAM Contractors en nv Galère niet langer in de aandeelhoudersstructuur zijn opgenomen.

3.14. Het tweede voorstel bevat de volgende verklaring van de nv BAM Contractors, de nv Galère en de nv Koninklijke BAM Groep:

“Bovendien, door, op het Plateau van de Heysel, het ontwerp, de realisatie, de financiering en het onderhoud van een congrescentrum toe te vertrouwen aan de Projectvennootschap ‘BAM’, en het ontwerp en de realisatie van een hotel toe te vertrouwen aan de Projectvennootschap ‘Hotel’, zullen de Deelnemer en Koninklijke BAM Groep (de derde entiteit op wiens capaciteiten de Deelnemer beroep heeft gedaan voor de verantwoording van de voldoening aan de economische en financiële criteria van de kwalitatieve selectie) ernaar streven [in het Frans: “s’efforceront”] dat de Projectvennootschappen ‘BAM’ en ‘Hotel’ de financiële engagementen die respectievelijk nodig zijn voor het de

uitvoering van het Congrescentrum en het Hotel, zullen aangaan als Dienstverlener ten voordele van de Aanbestedende overheid.”

Het tweede voorstel bevat bovendien de volgende paragraaf:

“Indien de zogeheten ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ (Annex 14) die dient te worden ondertekend door de vennootschappen die deel uitmaken van het Consortium geïnterpreteerd moet worden als een verbintenis van die vennootschappen om aansprakelijkheden op zich te nemen die verder gaan dan de SPC die non-recourse gefinancierd wordt, zou dit moeilijk zijn om te verzoenen met wat de marktpraktijk en zelfs bankable is en dientengevolge onaanvaardbaar voor de deelnemer. Het is eerder marktpraktijk om de SPC te verzoeken een uitvoeringsgarantie te stellen (zoals voorzien in het huidige ontwerp van DBFM Overeenkomst) die bijkomende geruststelling biedt voor de Autoriteit dat de SPC haar verbintenissen zal nakomen. Bovendien zal de D&B onderaannemer (die in de vorm zal zijn van een tijdelijke handelsvennootschap van wie de leden hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn ten opzichte van de SPC) van de SPC zal eveneens een uitvoeringsgarantie stellen ten opzichte van de SPC (en haar kredietverstrekkers) om de SPC te garanderen (en haar kredietverstrekkers) dat alle D&B Werken zullen worden gerealiseerd conform de DBFM Overeenkomst op back-to-back basis. In het onderhavige geval, zal het Royal BAM Group zijn die de prestatie zal garanderen van het Congrescentrum D&B Werken.”

3.15. Op 7 juni 2016 beslist de raad van bestuur van de verwerende partij om het tweede voorstel van verzoeksters uit te sluiten en de twee andere voorstellen te behouden. Dit is de thans bestreden beslissing die, wat meer bepaald verzoeksters betreft, het volgende notuleert:

“4.2 Onderzoek van de overeenstemming van de tweede Voorstellen van elke deelnemer met betrekking tot de essentiële beginselen van de opdracht betreffende de realisatie van een congrescentrum en een hotel op het Heizelplateau (genaamd opdracht Neo II)

Op basis van het verslag van de gedelegeerd bestuurder, onderzoekt de raad de overeenstemming van de tweede Voorstellen van elke deelnemer met betrekking tot de essentiële beginselen van de opdracht Neo II en komt tot volgende bevindingen:

Gelet op de wet van 15 juni 2006 houdende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, meer in het bijzonder artikel 27;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 met betrekking tot de plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, meer in het bijzonder artikel 58 en artikel 111 tot en met 114,

Gelet op de opdrachtdocumenten, meer in het bijzonder de aankondiging van de opdracht, het beschrijvend document en de dialooggids;

Analyse van de overeenstemming van de Voorstellen

1. Overwegende dat elk van de drie Deelnemers die werden uitgenodigd tot de tweede Fase van de dialoog tijdig een tweede Voorstel hebben ingediend;

Dat de Vennootschap reeds in de opdrachtdocumenten die aan de Deelnemers in dit stadium werden overgemaakt, verschillende elementen heeft meegedeeld die vereist en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en die de offertes, in toepassing van artikel 114, §1, alinea 4 van het KB van 15 juli 2011, moeten bevatten; dat tijdens het onderzoek van de tweede Voorstellen vooraleer de gesprekken met de Deelnemers op te starten, de Vennootschap heeft vastgesteld dat één van hen essentiële beginselen van de opdrachtdocumenten niet heeft nageleefd.

Dat de artikels II.11 en II.12 van de Dialooggids van het beschrijvend Document en II.4 en II.5 van de Oriëntatiegids zoals overgemaakt in het begin van de tweede Fase van de dialoog weliswaar voorzien dat de Vennootschap en de Deelnemers eerst de tweede Voorstellen bespreken alvorens dat de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 111, §3 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, de meest voordelige Voorstellen rekening houdende met de gunningscriteria aanduidt; dat deze bepalingen voorzien dat slechts de drie meest voordelige Voorstellen voorlopig zullen worden meegenomen voor het vervolg van de dialoog en het voorwerp kunnen uitmaken van definitieve offertes;

Dat de tweede Voorstellen om nuttig met elkaar vergeleken te kunnen worden en het voorwerp van discussie te kunnen uitmaken, niettemin de essentiële beginselen van de opdrachtdocumenten, zoals uiteengezet onder punt 2 hierna, moeten respecteren; dat een objectieve vergelijking van de Voorstellen rekening houdende met de gunningscriteria en het opstellen van een voorlopige rangschikking met het oog op het aanduiden van de Voorstellen die het voorwerp kunnen uitmaken van definitieve offertes, uiteraard enkel zin heeft indien deze Voorstellen de essentiële beginselen van de opdracht en het door de opdrachtdocumenten vastgestelde gemeenschappelijk kader respecteren;

Dat, zelfs wanneer de opdrachtdocumenten voorzien dat de minst voordelige voorstellen slechts na de discussiebijeenkomsten geweerd zullen worden, het onnuttig lijkt de teams van de Deelnemers op te roepen om de Voorstellen uitvoerig te bespreken indien de substantiële onregelmatigheden waarmee ze behept zijn niet meer op wettelijke wijze kunnen worden gecorrigeerd en die dus op het einde van de tweede Fase van de dialoog, in elk geval en los van de inhoud van de komende besprekingen, geweerd moeten worden;

Dat bijgevolg, de Vennootschap zich gedwongen ziet om, in dit stadium, uitspraak te doen over de overeenstemming van de drie

Voorstellen met betrekking tot de essentiële beginselen van de opdracht;

2. Overwegende dat de essentiële beginselen van de opdracht de volgende zijn:

- Zoals blijkt uit de aankondiging van de opdracht en de beslissing om de opdracht op te starten, is de opdracht een unieke opdracht die betrekking heeft op de geïntegreerde realisatie van een congrescentrum en een hotel;

- Het artikel I.11 van de Dialooggids staat de wijziging van de samenstelling van de geselecteerde kandidaten enkel toe indien de Vennootschap toestemt en in behoorlijk verantwoorde gevallen; het voorziet met name het volgende:

‘In geval van bijzondere en behoorlijk gemotiveerde omstandigheden kunnen wijzigingen in de samenstelling en de identiteit van de leden van de Deelnemer of van derde entiteiten waarop de Deelnemer een beroep heeft gedaan, worden toegestaan in de loop van de procedure die op de selectie volgt, op voorwaarde dat permanent aan de Uitsluitingsgronden en aan de in de Aankondiging van de Opdracht opgelegde minimumcriteria voor de economische en financiële draagkracht of technische bekwaamheid voldaan is. De Aanbestedende Overheid behoudt zich hoe dan ook het recht voor om enige wijziging te weigeren die zou leiden hetzij tot een uitstap uit het consortium, hetzij tot een ontlasting van de verbintenissen vanwege de architecten, aannemers en (gedelegeerde) opdrachtgevers die houder zijn van de referenties vereist in punt III.2.3 van de Aankondiging van de Opdracht.

Een wijziging van de samenstelling van het consortium vereist steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Overheid. Deze toestemming mag pas worden verleend als hiermee vroegere beslissingen, in het bijzonder met betrekking tot de kwalitatieve selectie, niet worden herzien. Elk verzoek tot wijziging moet derhalve steunen op de noodzakelijke documenten die de Aanbestedende Overheid in de gelegenheid stellen de weerslag van de wijziging met kennis van zaken in te schatten.’;

- Het punt III.1.3) van de aankondiging voorziet dat ‘elk lid (van het consortium) dat zich kandidaat stelt wordt gemeenschappelijk en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid’; in principe moet een opdracht geplaatst volgens de procedure van de concurrentiedialoog, op grond van de artikels 111 en 114 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, toegekend worden aan de geselecteerde kandidaat die de beste offerte indient; het artikel I.13 van de Dialoogleidraad biedt niettemin de mogelijkheid aan de consortia om de uitvoering van de opdracht aan één of meer projectvennootschappen (hierna ‘SPV’) toe te vertrouwen; deze bepaling verduidelijkt dat indien het consortium-opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht aan één of meerdere SPV’s toevertrouwt, de offertes een waarborg moeten

bevatten voor de financiële verplichtingen van de projectvennootschap(pen) verbonden aan de uitvoering van onderhavige opdracht, die door alle leden van het consortium hoofdelijk wordt toegekend; in de loop van de eerste Fase van de dialoog, hebben alle drie Deelnemers in hun eerste Voorstel voorzien om de opdracht via een SPV uit te voeren; zij hebben alle drie de Vennootschap geïnformeerd dat een hoofdelijke verbintenis van de leden van het consortium-opdrachtnemer samen en voor de SPV's voor de goede uitvoering van de opdracht gedurende de volledige uitvoeringsfase van de opdracht streng was rekening houdende met de heersende marktpraktijken; dat de regel van de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals vastgelegd vanaf de aankondiging en in artikel I.13 van de Dialooggids (ook hernomen in artikel I.8 van de Oriëntatiegids), dientengevolge versoepeld en verfijnd werd in de tweede Fase van de dialoog, het essentiële karakter ervan echter uitdrukkelijk bevestigd werd in de verschillende documenten van de opdracht Neo II alsook in de gegeven antwoorden van de Vennootschap op de vragen van de Deelnemers; Zo voorziet artikel I.3.6. van de Oriëntatiegids dat het contractueel begrip van onderhavige opdracht op het volgende essentiële beginsel berust: 'de hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelgenoten van de Deelnemer voor de uitvoering van de opdracht, en wel op grond van de beginselen die hieronder voor elk voorwerp worden vermeld:

- o Deze hoofdelijke aansprakelijkheid moet volledig zijn tijdens de bouwfase, zowel voor het Congrescentrum als voor het Hotel;

- o Voor het Hotel moet deze hoofdelijke aansprakelijkheid worden aangehouden gedurende een redelijke exploitatieperiode die wordt omschreven door de Heads of Terms, en op voorwaarden overeen te komen, ook in geval van overdracht van een deel of van de totaliteit van de rechten op het Hotel en/of de exploitatie hiervan of in geval van overdracht van aandelen van de projectvennootschap waaraan de bouw en/of de exploitatie en/of het beheer van het Hotel zou worden toevertrouwd';

- Het principe van budgettaire deconsolidatie met betrekking tot de regels van ESR-2010 is eveneens een essentieel beginsel van de opdracht; De DBFM-modelovereenkomst met betrekking tot het congrescentrum (hierna 'Modelovereenkomst') en de Heads of Terms met betrekking tot het hotel (hierna 'HoT Hotel ') zijn opgesteld opdat het project zou deconsolideren; alle voorstellen of suggesties van de Deelnemers betreffende de twee ontwerp-overeenkomsten moeten compatibel blijken te zijn met de naleving van deze voor de Vennootschap essentiële verplichting;

- Het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals gemodelleerd in de Oriëntatiegids) en het principe van de budgettaire deconsolidatie zijn meerdere keren en op expliciete wijze – deze term werd overigens onderlijnd in het voornoemde artikel I.3.6 -als essentieel aangeduid;

Het is dus in essentie in het licht van deze essentiële beginselen dat de regelmatigheid van de Voorstellen zoals ingediend door de kandidaten in het kader van hun tweede offertes beoordeeld moet worden.

A. Analyse van het Voorstel van Deelnemer A

3. Overwegende dat, in hun tweede Voorstel, de twee leden die deel uitmaken van het consortium A (BAM Contractors en Galère) aangeven dat zij de uitvoering van de opdracht aan twee SPV's zullen toevertrouwen, één verantwoordelijk voor het congrescentrum en de andere verantwoordelijk voor het hotel; dat zij niettemin slechts aandeelhouders van de twee SPV's op het ogenblik van de gunning van de opdracht zullen zijn; dat hun participatie overigens zeer eng wordt omschreven; dat elk van de twee leden van het consortium slechts 0,1 % van de aandelen in elk van de twee SPV's zal bezitten; dat dit een uiterst kleine participatie in het kapitaal van de twee SPV's inhoudt; dat zij geen aandeelhouders – zelfs niet in beperkte mate – zullen zijn van de twee SPV's vanaf de sluiting van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 114, §3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en derhalve wanneer de overeenkomst uitgevoerd zal worden; dat de twee SPV's vanaf de sluiting van het contract volledig in handen zullen zijn van derde vennootschappen, die de Vennootschap, per definitie, niet geselecteerd heeft en waaromtrent in de ingediende kandidatuur geen informatie werd verschaft; dat immers het tweede Voorstel van consortium A voorziet dat BAM PPP Infrastructure Coöperatie U.A. alle aandelen van de SPV verantwoordelijk voor het congrescentrum zal bezitten en dat Ghelamco Invest alle aandelen van de SPV verantwoordelijk voor het hotel zal bezitten; Dat uit het voorgaande volgt dat dit contractueel proces veronderstelt dat de twee leden van consortium A die door de Vennootschap geselecteerd werden zich niet ten aanzien van de Vennootschap verbinden om de opdracht uit te voeren, hun uiterst geringe participatie in de twee SPV's kan deze vaststelling niet verhullen, nu deze participatie uitdrukkelijk beperkt is tot het stadium van de gunning van de opdracht; dat de leden van het consortium A niet op voorhand door middel van een gemotiveerde vraag om een wijziging van het consortium hebben verzocht en zij ook geen andere bijzondere omstandigheid inroepen die zou rechtvaardigen dat zij de opdracht, voor dewelke zij geselecteerd zijn, niet zelf uitvoeren – direct of via een nog te creëren projectvennootschap; dat op grond van artikel I.11 van de Dialooggids, elke wijziging van de samenstelling van de consortia altijd het voorafgaand akkoord van de Vennootschap moet verkrijgen; dat de Vennootschap zich eveneens het recht heeft voorbehouden om elke wijziging van de samenstelling van de consortium-kandidaat te weigeren indien dit zou leiden tot een uitstap van de geselecteerde leden uit het consortium; dat het contractueel proces zoals voorgesteld door het consortium A in zijn tweede Voorstel erop neer komt dat de

Vennootschap verplicht wordt de opdracht toe te vertrouwen aan SPV's waarvan de aandeelhouders vennootschappen zijn die niet werden geselecteerd, die zelfs niet vermeld werden in de ingediende kandidatuur en waarvoor bovendien niet wordt aangetoond dat zij voldoen aan de criteria voor de economische en financiële draagkracht van de aankondiging van de opdracht;

Dat dit contractueel proces dat impliceert, dat reeds voor de sluiting van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 114, §3 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, een definitieve uitstap van de geselecteerde leden uit het consortium gebeurt, dus artikel I.11 van de Dialooggids schendt.

4. Overwegende dat, zelfs wanneer zij de uitvoering van de opdracht toevertrouwen aan SPV's die op het moment van de sluiting van het contract volledig in handen zijn van vennootschappen die niet geselecteerd werden en zelfs niet vermeld werden in de ingediende kandidaatsstelling, de leden van het consortium A het principe van de aansprakelijkheid, ten aanzien van de Vennootschap, voor de verplichtingen van de SPV's, en a fortiori, het principe van de hoofdelijkheid, zoals vastgelegd in voornoemd artikel I.3.6., niet aanvaarden; Dat zij het essentiële beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid in alle stadia van de uitvoering van de opdracht verwerpen, het is te zeggen gedurende de constructiefase van het congrescentrum en het hotel en tijdens de redelijke exploitatieperiode van het hotel; dat zij immers preciseren dat voorzien in een hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de geselecteerde kandidaten om garant te staan voor de verplichtingen die op het moment van de sluiting van de overeenkomst door de SPV, verantwoordelijk voor het congrescentrum, zullen worden aangegaan, noch conform met de heersende marktpraktijken noch 'bancable' zou zijn; dat zij in deze zin beweren dat:

'If the so-called 'engagement solidaire' (Annex 14) to be signed by the companies forming part of the Consortium is to be interpreted as a commitment of those companies to take on liabilities which go beyond the nonrecourse financed SPC, this would be difficult to reconcile with what is market practice and even bankable and therefore not acceptable for the Candidate. It is rather market-practice to request the SPC to post a performance guarantee (as foreseen in the current draft DBFM Agreement) which provides additional comfort for the Authority that the SPC will perform its obligations. In addition to this, the D&B subcontractor (which will be in the form of a temporary commercial association/tijdelijke handelsvennootschap/société momentanée which members will be joint and several liable towards the SPC) of the SPC will also post a performance guarantee towards the SPC (and its lenders) to guarantee the SPC (and its lenders) that all D&B Works will be realized in conformity with the DBFM Agreement on a back-to-back basis. In the case at hand, it will be the Royal BAM

Group who will guarantee the performance of the Convention Centre D&B Works' (cf. Farde 2, p. 330);

Dat zij dus duidelijk aangeven dat het beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor hen onaanvaardbaar is tijdens de constructiefase van het congrescentrum; dat de leden van het consortium A in hun tweede Voorstel ook niet voorzien in een hoofdelijke aansprakelijkheid tijdens de constructiefase van het hotel of tijdens een redelijke exploitatieperiode van het hotel (cf. Farde 2, pp. 346-349);

Dat, trouwens, de Koninklijke BAM Groep – die het consortium A, op het moment van de selectie, toeliet om in toepassing van artikel 74 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, aan te tonen dat voldaan werd aan de criteria voor de economische en financiële draagkracht van de aankondiging van de opdracht – geen enkele participatie zal bezitten in de twee SPV's die de opdracht zullen uitvoeren – dat de Koninklijke BAM Groep zich er ook niet toe verbindt, om gedurende welk stadium van de uitvoering van de opdracht dan ook, haar middelen ter beschikking te stellen van de twee SPV's die de opdracht zullen uitvoeren;

Dat de weigering, door het consortium A, om in haar contractueel project het essentiële beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid op te nemen, nog werd bevestigd door de nietszeggende verklaring van de leden van het consortium en de Koninklijke BAM Groep, volgens hetwelke zij zich zouden beperken om 'ernaar te streven' ('s'efforceront') dat de twee SPV's, als prestatieplichtigen, ten voordele van de Vennootschap, de nodige financiële verplichtingen voor de uitvoering van het congrescentrum en het hotel zullen aangaan (cf. Farde 2, pp. 169 et 229); Dat een dergelijke verklaring grotendeels verstoken is van iedere betekenis, in de zin dat zij geen enkele resultaatsverbintenis in hoofde van de leden van het consortium of de Koninklijke BAM Groep ten aanzien van de Vennootschap met zich meebrengt;

Dat de tegenvoorstellen die door het consortium A als alternatief voor het in de opdrachtdocumenten vastgestelde beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid naar voren werden geschoven, niet aanvaard kunnen worden; dat deze tegenvoorstellen in werkelijkheid geen alternatieven voor dit beginsel zijn, in de mate dat hierin reeds als zodanig door de opdrachtdocumenten werd voorzien of dat zij niet bestaan uit garanties die ten voordele van de Vennootschap worden toegekend en waarop deze zich zou kunnen beroepen;

Dat aldus, voor het congrescentrum, het consortium A aangeeft dat een uitvoeringsgarantie ('performance guarantee') zal worden gegeven; dat deze garantie echter reeds voorzien is in artikel 4.2 (a) van de DBFM-ontwerpovereenkomst; dat het consortium ook niet voorziet in een bedrag hoger dan het bedrag van 5.000.000 EUR zoals vastgelegd in de DBFM-ontwerpovereenkomst; dat de tweede garantie betrekking heeft op de goede uitvoering van de

verplichtingen van de aannemers door de tijdelijke vennootschap die instaat voor de constructiewerken van het congrescentrum en die zal bestaan uit de huidige leden van het consortium (BAM Contractors en Galère); dat deze tweede garantie door de Koninklijke BAM Groep echter niet ten voordele van de Vennootschap, maar van de SPV verantwoordelijk voor het congrescentrum, wordt toegekend;

Dat, voor wat betreft het hotel, de SPV die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht een uitvoeringsgarantie toekent ten voordele van de Vennootschap; dat deze garantie echter reeds voorzien werd in annex 1 van de HoT Hotel; dat bovendien het consortium niet voorziet in een bedrag hoger dan het bedrag van 2.500.000 EUR zoals voorzien in de HoT Hotel; dat de tweede garantie betrekking heeft op de goede uitvoering van de verplichtingen van de aannemers door de tijdelijke vennootschap die instaat voor de constructiewerken van het hotel en die zal bestaan uit de huidige leden van het consortium (BAM Contractors en Galère); dat deze tweede garantie door de Koninklijke BAM Groep echter niet ten voordele van de Vennootschap, maar van de SPV verantwoordelijk voor het congrescentrum, wordt toegekend; Dat deze zogenaamde alternatieve oplossingen dus totaal onvoldoende zijn om de weigering van de leden van het consortium A om zich hoofdelijk te verbinden ten einde de verplichtingen van de twee SPV's te garanderen, te verhelpen.

5. Overwegende dat naast het gegeven dat zij verschillende aandeelhouders in de twee SPV's voorzien en het essentiële beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet respecteren, de leden van het consortium A in hun contractueel project geen enkele clausule opnemen die een band creëert tussen de verbintenissen met betrekking tot het hotel en degene met betrekking tot het congrescentrum (cf. Farde 2, pp. 346-347);

Dat de leden van het consortium A hoogstens een 'samenwerkingsovereenkomst' voorstellen op grond waarvan de twee SPV's onderling zullen samenwerken teneinde de synergieën te vergroten en te vermijden dat hun respectievelijke verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap in het gevaar zullen komen ((cf. Farde 2, p. 421); dat deze 'samenwerkingsovereenkomst' onvoldoende en onaanvaardbaar is aangezien deze niet direct door de Vennootschap ten aanzien van de SPV's zou kunnen worden ingeroepen;

Dat de afwezigheid van elke contractuele band tussen de twee SPV's, gecombineerd met de verschillende samenstellingen van het aandeelhouderschap bij de twee SPV's en met de expliciete weigering van een hoofdelijke aansprakelijkheid in hoofde van de leden van het consortium, in werkelijkheid neerkomt op het opheffen van de uniciteit van de opdracht die betrekking heeft op de geïntegreerde realisatie, en niet gescheiden, van een congrescentrum en een hotel.

6. Overwegende dat de concurrentiedialoog wel toelaat om alle aspecten van de opdracht te bespreken, maar artikel 5 van de wet van 15 juni 2006 niettemin de verplichting oplegt aan de aanbestedende overheid om de kandidaten/inschrijvers in overeenstemming met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie te behandelen, transparant te handelen en de mededinging te garanderen; dat deze beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, van transparantie en van mededinging, geconcretiseerd worden in de concurrentiedialoog, namelijk, door het verbod, zoals voorzien in artikel 111, §4 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, om in de loop van de gunningsprocedure de essentiële elementen van de aankondiging en het beschrijvend document te wijzigen, wanneer deze wijziging de mededinging kan verstoren of een discriminerend effect kan hebben.

Dat trouwens, zoals hiervoor reeds aangegeven, een objectieve vergelijking van de Voorstellen aan de hand van de gunningscriteria en het vaststellen van een rangschikking uiteraard slechts zin hebben indien deze Voorstellen voldoen aan de essentiële beginselen van de opdracht en het gemeenschappelijk kader zoals vastgesteld door de opdrachtdocumenten;

Dat, daarom, het geven dat in casu de gunningswijze die van de concurrentiedialoog is, niet impliceert, dat de aanbestedende overheid, zelfs in de stadia voorafgaand aan de indiening van de offertes, zonder schending van het gelijkheidsbeginsel Voorstellen zou kunnen aanvaarden, die verder gaan dan het formuleren van loutere suggesties en de essentiële beginselen van de betrokken opdracht opzij schuiven en dus verwerpen als onaanvaardbaar en die, dientengevolge, aangetast zijn door substantiële onregelmatigheden;

Dat uit het voorgaande voortvloeit dat het consortium A noch het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid, noch artikel I.11 van de Dialoogleiddraad, noch het unieke karakter van de opdracht respecteert;

Dat meer in het bijzonder wat betreft de eis van de hoofdelijke aansprakelijkheid, deze, in tegenstelling tot wat consortium A beweert, noch onverenigbaar met de heersende marktpraktijken, noch niet-financierbaar lijkt te zijn, aangezien de andere Deelnemers dit wel opnemen in hun tweede Voorstel; Dat dit bovendien niet beantwoordt aan de behoeften van de Vennootschap, en een opheffing van dit principe – uitdrukkelijk als essentieel aangeduid – wegens de door het consortium A ingeroepen redenen, niet overwogen kan worden, op straffe van vervalsing van de mededinging en bevoordeling van het consortium, en dit ten nadele van de twee andere Deelnemers die wel aanvaarden om hiermee rekening te houden in hun contractueel project;

Dat het principe van gelijkheid en non-discriminatie de Vennootschap verbiedt het consortium A te vragen om een nieuw

Voorstel in te dienen dat in overeenstemming zou zijn met de essentiële beginselen van de opdracht; Dat een dergelijke houding er inderdaad op neer zou komen dat consortium A de mogelijkheid krijgt om te verhelpen aan substantiële onregelmatigheden en om een volledig nieuw contractueel project voor te stellen in vergelijking met wat het consortium had voorzien in zijn tweede Voorstel; dat dit dus als gevolg zou hebben dat tijdens de gunning een deelnemer, die in tegenstelling tot de twee andere, duidelijk geweigerd heeft om de eisen van de aanbestedende overheid, na te leven terug zou worden ‘opgevist’ en dat het de deelnemer zou worden toegestaan om een voorstel te regulariseren dat niet regelmatig was op punten die uitdrukkelijk als essentieel werden bestempeld;

Dat het tweede Voorstel van het consortium A aldus wegens elk van de hierboven vermelde motieven niet in aanmerking kan worden genomen;

Dat het past om te verduidelijken, voor zoveel als nodig, dat men zich niet bevindt in de situatie zoals beschreven in de artikels II.8 en II.11 van de Dialooggids en II.3 en II.4 van de Oriëntatiegids; dat het er in casu voor de aanbestedende overheid op zou neerkomen om aan het consortium A te vragen om in zijn tweede Voorstel of in een mogelijk later voorstel, de essentiële eisen van de opdracht te integreren wat het voordien bewust geweigerd heeft te doen; dat door dit te doen, de aanbestedende overheid het beginsel van de gelijkheid zou schenden en dit ten voordele van één enkele inschrijver, door deze uit te nodigen om zijn voorstel te regulariseren door een substantiële wijziging die betrekking heeft op essentiële punten van de opdracht die zich sinds het begin van de procedure aan eenieder opdringen;

Overwegende dat, wanneer het Voorstel van consortium A onregelmatig is wegens de hierboven vernoemde motieven, het niet meer nuttig is om zich bovendien nog uit te spreken over de vraag of het consortium het essentiële beginsel van de deconsolidatie al dan niet heeft gerespecteerd;

Overwegende dat dientengevolge het consortium A, wiens enige Voorstel is afgewezen, definitief van de procedure van de concurrentiedialoog is uitgesloten.”

IV. Weergave van de neergelegde stukken

4.1. In de mate waarin in dit arrest stukken ter sprake komen die door verzoeksters als vertrouwelijk worden bestempeld, wordt enkel de inhoud ervan weergegeven zoals zij die in hun verzoekschrift vermelden en waarvan zij ter terechtzitting bevestigen, te verzaken aan de gevraagde vertrouwelijkheid.

In de mate waarin in dit arrest stukken ter sprake komen die door de verwerende partij als vertrouwelijk worden bestempeld, wordt enkel de inhoud ervan weergegeven zoals de verwerende partij deze in haar nota met opmerkingen citeert en waarbij zij dus in die mate zelf de door haar ingeroepen vertrouwelijkheid van de bedoelde stukken heeft gelicht, zoals zij overigens ter terechtzitting bevestigt.

In de huidige stand van het geding wordt voor het overige het verzoek tot vertrouwelijke behandeling vanwege de partijen ingewilligd.

4.2. Voor zover stukken enkel in het Frans of in het Engels zijn opgesteld, neemt dit arrest om proceseconomische redenen als ‘citaat’ de vrije vertaling ervan over zoals die is aangereikt door een van de partijen, zonder door de andere partij(en) te zijn betwist.

V. Herinnering aan de schorsingsvoorwaarden

5. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gelezen in samenhang met artikel 15 van de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, moet enkel worden onderzocht of in de voorliggende vordering tot schorsing die is ingesteld volgens de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid wordt aangevoerd.

VI. Onderzoek van de middelen

A. Tweede middel, tweede onderdeel

Uiteenzetting van het middelonderdeel

6. Een tweede middel, tweede middelonderdeel, is geput uit de schending van artikel 27 van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ (hierna: de overheidsopdrachtenwet), artikel 111, § 1, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ‘betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren’ (hierna KB Plaatsing), de punten I.11 en I.13 van de dialooggids, punt I.8 van de oriënteringsgids, de materiële motiveringsplicht, het beginsel *patere legem quam ipse fecisti*, het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel, het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel,

“doordat, tweede onderdeel, de verwerende partij verkeerdelijk stelt dat de vereiste inzake de juridische vorm waaronder de leden van de verzoekende partij zich jegens de verwerende partij solidair en hoofdelijk verbinden tot de uitvoering van de Opdracht een essentieel voorschrift van de Opdracht betreft op basis waarvan het Tweede Voorstel vanwege verzoekende partij onregelmatig kan worden verklaard en kan worden uitgesloten.

Terwijl de vereiste inzake de juridische vorm waaronder de leden van de verzoekende partij zich jegens de verwerende partij solidair en hoofdelijk verbinden tot de uitvoering van de Opdracht een voorschrift van de Opdracht behelst waarover twijfel bestaat en dat daarenboven niet op straffe van onontvankelijkheid is gesteld, waardoor de vereiste geen voorschrift van de Opdracht uitmaakt op basis waarvan het Tweede Voorstel vanwege verzoekende partij onregelmatig kan worden verklaard en kan worden uitgesloten.”

In de toelichting bij het middelonderdeel betogen verzoeksters dat sinds de aanvang van de concurrentiegerichtte dialoog twijfel en verwarring bestaat bij de deelnemers over de voorwaarde waaronder de leden van de deelnemers zich jegens de verwerende partij solidair en hoofdelijk dienen te verbinden tot de uitvoering van de opdracht.

Punt I.13 van de dialooggids bepaalt dat de na te leven voorwaarden van deze vereiste in de loop van de dialoog zullen worden vastgesteld. Ter gelegenheid van het indienen van het eerste voorstel hebben zij een bemerking geformuleerd over een aanpak-op-maat van de onderscheiden projecten congrescentrum en hotel, met verzoek dit te bespreken in de volgende fase van de plaatsingsprocedure. Gelet op de goedkeuring van haar eerste voorstel en het ontvangen van een verzoek tot indiening van een tweede voorstel, gingen zij er ook van uit dat dialoogvoering inzake de onderliggende vereiste tot de mogelijkheden behoorde.

Uit het verloop van de concurrentiegerichte dialoog blijkt overigens dat de dubbelzinnigheid die gepaard gaat met dit voorschrift ook speelde bij de overige deelnemers. Verzoeksters citeren verschillende vragen die de verwerende partij naar aanleiding van de indiening van de tweede voorstellen met betrekking tot deze vereiste ontving.

Punt I.8 van de oriënteringsgids creëerde volgens verzoeksters in het kader van de tweede dialoogfase bijkomende verwarring. Zo dient uit dit artikel te worden afgeleid dat het voorschrift enkel vereist is voor zover dit voor de behoorlijke uitvoering van het project noodzakelijk is en dat aldus de verwerende partij openstaat tot dialoogvoering om de concrete invulling van het voorschrift te kunnen bepalen.

Aangezien twijfel bestaat omtrent de interpretatie van het beschrijvend document vinden de civielrechtelijke regels voor de interpretatie van overeenkomsten – artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek – toepassing, die een uitlegging in het voordeel van verzoeksters voorstaan.

Verzoeksters merken nog op dat de opdrachtdocumenten op geen enkele plaats bepalen dat het niet respecteren van het voorschrift de definitieve uitsluiting tot gevolg heeft.

In ondergeschikte orde, in de hypothese dat de vereiste ondubbelzinnig een essentieel voorschrift van de opdracht uitmaakt dat is gesteld op straffe van onontvankelijkheid, dient volgens verzoeksters “gewezen worden op het feit dat de enkele uitsluiting van verzoekende partij en de niet uitsluiting van de overige twee Deelnemers aan de concurrentiegerichte dialoog, impliceert dat laatstgenoemden een Tweede Voorstel hebben ingediend waarbij zij volledig, in alle aspecten, voldoen aan het voorschrift inzake de juridische vorm waaronder de leden van de Deelnemers zich jegens de verwerende partij solidair en hoofdelijk verbinden tot de uitvoering van de Opdracht”. Een andere opvatting, zo merken verzoeksters op, zou een discriminatoire handelwijze uitmaken ten opzichte van henzelf.

Beoordeling

7.1. Artikel 27 van de overheidsopdrachtenwet luidt:

“Een aanbestedende overheid kan de concurrentiedialoog slechts gebruiken in geval van een bijzonder ingewikkelde opdracht, wanneer zij:
1° objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische oplossingen, en
2° van oordeel is dat de toepassing van de open of beperkte procedures het onmogelijk maakt de opdracht te plaatsen.
De Koning bepaalt de na te leven voorschriften bij een concurrentiedialoog. Deze voorschriften zijn onder meer:
- de gelijke behandeling van alle deelnemers tijdens de dialoog;
- de niet-bekendmaking aan de deelnemers van de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer verstrekte vertrouwelijke inlichtingen zonder instemming van laatstgenoemde.”

7.2. Artikel 111, § 1, KB Plaatsing luidt:

“Bij concurrentiedialoog maakt de aanbestedende overheid een aankondiging van opdracht bekend overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 7 en stelt ze een beschrijvend document op. Ze vermeldt in de aankondiging van opdracht de eisen inzake selectie overeenkomstig artikel 58, § 1. Daarnaast bepaalt ze in de aankondiging van opdracht of in het beschrijvend document haar behoeften en eisen, alsook de gunningscriteria. Deze gunningscriteria moeten verband houden met het

voorwerp van de opdracht en een objectieve vergelijking van de offertes mogelijk maken op basis van een waardeoordeel.”

7.3. Artikel 113, § 1, KB Plaatsing luidt:

“De aanbestedende overheid start een dialoog op met de geselecteerden, met het doel na te gaan en te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan haar behoeften te voldoen. Ze verschaft de deelnemers een voldoende termijn om de dialoog voor te bereiden.

De dialoog gebeurt met elke deelnemer afzonderlijk.

Tijdens de dialoog kan de aanbestedende overheid met de deelnemers alle aspecten van de opdracht bespreken. Ze waarborgt daarbij de gelijke behandeling van alle deelnemers. In het bijzonder mag ze geen discriminerende informatie verstrekken die bepaalde deelnemers kan bevoordelen. Ze mag evenmin de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer verstrekte vertrouwelijke inlichtingen aan de andere deelnemers bekendmaken zonder de instemming van eerstgenoemde, zowel tijdens als na afloop van de procedure.”

7.4. De punten I.11 en I.13 van de dialooggids bepalen het volgende:

“I.11 Omschrijving en wijziging van de samenstelling en de identiteit van de Deelnemers:

De Deelnemers aan de dialoog zijn hetzij een unieke economische operator, hetzij een consortium van economische operatoren, die de vorm aannemen van een tijdelijke handelsmaatschappij of een andere vereniging. In het geval van een consortium zijn alle plichten van de Deelnemer, behoudens andersluidende vermelding in deze Dialooggids, van toepassing op alle leden van het consortium. Elk lid is ten opzichte van de Aanbestedende Overheid gemeenschappelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de Offerte die zijn consortium indient.

In geval van consortium verbindt de Deelnemer zich ertoe de samenstelling van de groepering van economische operatoren die hij naar aanleiding van de kwalitatieve selectie heeft voorgesteld niet te wijzigen.

In geval van bijzondere en behoorlijk gemotiveerde omstandigheden kunnen wijzigingen in de samenstelling en de identiteit van de leden van de Deelnemer of van derde entiteiten waarop de Deelnemer een beroep heeft gedaan, worden toegestaan in de loop van de procedure die op de selectie volgt, op voorwaarde dat permanent aan de Uitsluitingsgronden en aan de in de Aankondiging van de Opdracht opgelegde minimumcriteria voor de economische en financiële draagkracht of technische bekwaamheid voldaan is. De Aanbestedende Overheid behoudt zich hoe dan ook het recht voor om enige wijziging te weigeren die zou leiden hetzij tot een uitstap uit het consortium, hetzij tot een ontlasting van de verbintenissen vanwege de architecten, aannemers en (gedelegeerde) opdrachtgevers die houder zijn

van de referenties vereist in punt III.2.3 van de Aankondiging van de Opdracht.

Een wijziging van de samenstelling van het consortium vereist steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbestedende Overheid. Deze toestemming mag pas worden verleend als hiermee vroegere beslissingen, in het bijzonder met betrekking tot de kwalitatieve selectie, niet worden herzien. Elk verzoek tot wijziging moet derhalve steunen op de noodzakelijke documenten die de Aanbestedende Overheid in de gelegenheid stellen de weerslag van de wijziging met kennis van zaken in te schatten.

Het team dat aldus is samengesteld kan in de loop van de dialoog bovendien worden aangevuld met operatoren die beschikken over specifieke vaardigheden voor de verwezenlijking van bepaalde delen van de opdracht en waarvan de aanwezigheid binnen de kandidaatteams tijdens de fase van de kwalitatieve selectie niet vereist was.

Ook hier kunnen latere wijzigingen met betrekking tot de samenstelling en de identiteit van deze aanvullende leden in het team van de Deelnemer enkel worden toegestaan in bijzondere omstandigheden die op een onderbouwde wijze onderworpen worden aan de beoordeling van de Aanbestedende Overheid, en dit enkel op voorwaarde dat deze niet worden doorgevoerd op een ogenblik van de procedure dat ertoe zou leiden dat reeds verrichte beoordelingen en vergelijkingen van de verschillende Voorstellen door de Aanbestedende Overheid op de helling komen te staan. De Deelnemers kunnen geenszins aanspraak maken op een recht op dit soort wijziging.

[...]

I.13 Vorm van het Deelnemend consortium/Oprichting van een Projectvennootschap:

De Deelnemer kiest de juridische vorm waaronder zijn leden zich jegens de Aanbestedende Overheid solidair en hoofdelijk verbinden tot de uitvoering van de opdracht, gericht op een behoorlijke verwezenlijking van het project volgens de na te leven voorwaarden die in de loop van de dialoog worden vastgesteld.

Indien de Deelnemer een Projectvennootschap wenst op te richten met het oog op de uitvoering van de opdracht, dan dient deze dit te vermelden in zijn Tweede Voorstel en hierin, op zijn minst in grote lijnen (term sheet), de volgende elementen te beschrijven :

De ontwerpstatuten van de Projectvennootschap(pen);

De bedragen van het maatschappelijk kapitaal waarop elke aandeelhouder zal inschrijven, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal dat bij de oprichting door elke aandeelhouder individueel zal worden gestort en de periodes waarin voorzien wordt dat het eventuele saldo van het maatschappelijk kapitaal zal worden volgestort;

het aanvankelijke aandeelhouderschap van de Projectvennootschap, rechtstreeks en onrechtstreeks, en in voorkomend geval ook het toekomstige aandeelhouderschap indien dit reeds gepland is, in functie waarvan de rechtstreekse en onrechtstreekse controle op de Projectvennootschap kan worden vastgesteld;

[...]

De contracten op grond waarvan de middelen van de Deelnemer (en indien het een consortium betreft, van de leden van het consortium) die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gesteld zullen worden van de projectvennootschap voor de duur en de behoeften van de opdracht, tenzij deze in natura in de Projectvennootschap worden ingebracht.

[...]

Overeenkomstig de hogervermelde punten I.10 en I.11 dient de door de Deelnemer opgerichte Projectvennootschap, wanneer de Deelnemer in de loop van de Dialoog de leden van het consortium in de plaats wenst te stellen van de Projectvennootschap, in regel te zijn met betrekking tot de Uitsluitingsgronden en in het licht van de middelen die hem ter beschikking zijn gesteld om te beschikken over de economische en financiële draagkracht of technische bekwaamheid bepaald in de Aankondiging van de Opdracht tijdens de hele gunningsprocedure van deze opdracht.

De Aanbestedende Overheid dient overeenkomstig het hogervermelde punt I.11 uitdrukkelijk zijn goedkeuring te verlenen aan de vervanging van het Deelnemend consortium zonder rechtspersoonlijkheid door een Projectvennootschap. Gebeurt dit niet, dan worden de leden van het Deelnemend Consortium beschouwd als enige gesprekspartners die in rechte verbonden zijn ten opzichte van de Aanbestedende Overheid en zijn zij derhalve rechtstreeks aansprakelijk voor de uitvoering van deze opdracht.

Door de uitvoering van de opdracht toe te vertrouwen aan een Projectvennootschap verbindt de Deelnemer zich er onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe dat de projectvennootschap effectief toegang krijgt tot de kennis, de ervaring, de vakbekwaamheid en de financiële en andere middelen van deze Deelnemer die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. Een uitdrukkelijke verbintenis in die zin vanwege de Deelnemer dient aan zijn Tweede Voorstel/Definitieve Offerte te worden toegevoegd, alsmede een waarborg voor de financiële verplichtingen van de Projectvennootschap verbonden aan de uitvoering van deze opdracht door alle leden van het consortium, en dit hoofdelijk of middels een bankgarantie op eerste verzoek.”

7.5. De punten I.3.6 en I.8 van de oriënteringsgids bepalen het volgende:

“I.3.6. Ontwerpovereenkomst en Heads of Terms

Het contractueel begrip van deze opdracht berust op de twee onderstaande beginselen die door de Aanbestedende Overheid worden aanzien als essentieel:

- de budgettaire deconsolidatie van de contractuele verbintenissen van de vennootschap NEO in het licht van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 2010 (ESR2010);

- de hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelgenoten van de Deelnemer voor de uitvoering van de opdracht, en wel op grond van de beginselen die hieronder voor elk voorwerp worden vermeld:

o deze hoofdelijke aansprakelijkheid moet volledig zijn tijdens de bouwfase, zowel voor het Congrescentrum als voor het Hotel;

o voor het Hotel moet deze hoofdelijke aansprakelijkheid worden aangehouden gedurende een redelijke exploitatieperiode die wordt omschreven door de Heads of Terms, en op voorwaarden overeen te komen, ook in geval van overdracht van een deel of van de totaliteit van de rechten op het Hotel en/of de exploitatie hiervan of in geval van overdracht van aandelen van de projectvennootschap waaraan de bouw en/of de exploitatie en/of het beheer van het Hotel zou worden toevertrouwd.

[...]

I.8 Vorm van het Deelnemende Consortium/Oprichting van een Projectvennootschap

De Deelnemer kiest de juridische vorm waarin zijn deelgenoten zich hoofdelijk en solidair verbinden tot de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de Aanbestedende Overheid, in de mate dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van het project en met naleving van de voorwaarden omschreven in de Ontwerpovereenkomst en de Heads of Terms en overeenkomstig de beginselen vermeld in het hogervermelde punt I.3.6.”

8. Hoewel gekenmerkt door een ruime appreciatievrijheid voor de aanbestedende overheid om aan de flexibele gunningswijze die de concurrentiegerichtte dialoog is, vorm te geven, is deze begrensd door het gelijkheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het mededingingsbeginsel zoals neergelegd in de algemene-beginselpaling van artikel 5 van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, dat de aanbestedende overheden gebiedt “de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze [te behandelen]”.

De artikelen 111 en 113 van het KB Plaatsing bepalen voorts dat “de essentiële elementen van de aankondiging en het beschrijvend document” in de loop van de gunningsprocedure niet kunnen worden gewijzigd, “wanneer dit de mededinging kan verstoren of een discriminerend effect kan hebben” (artikel 111, § 4) en dat de aanbestedende overheid tijdens de dialoog met de deelnemers alle aspecten van de opdracht kan bespreken, maar zij “waarborgt daarbij de gelijke behandeling van alle deelnemers” (artikel 113, § 2, derde lid). Volgens het Verslag

aan de Koning bij het KB Plaatsing zijn “de essentiële elementen bedoeld in artikel 111 [...] onder meer de selectie- en de gunningscriteria, de aanduiding van de fases en alle andere elementen die een invloed kunnen hebben op de mededinging”.

9.1. In de huidige stand van de procedure is de Raad van State van oordeel dat lectuur van de aankondiging en van het beschrijvend document – inzonderheid de dialooggids en de oriënteringsgids – er geen twijfel over kan laten bestaan bij de deelnemers dat het beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelnemers als een essentieel element ervan is opgevat.

9.2. Zo is reeds het volgende te lezen in de aankondiging:

“Indien een aanvraag tot deelneming uitgaat van een consortium:
Zijn alle plichten van een kandidaat, behoudens andersluidende vermelding in onderhavige aankondiging, van toepassing op alle leden van het consortium.

Duidt het consortium een contactpunt met de aanbestedende dienst aan, die als eerste gesprekspartner en piloot van het team optreedt tijdens de dialoog. Dit contactpunt kan tijdens de procedure worden gewijzigd, mits voorafgaande kennisgeving aan de aanbestedende dienst, en is voldoende beschikbaar en gemakkelijk bereikbaar voor de aanbestedende dienst (dit impliceert meer bepaald een woonplaatskeuze in België).

Elk lid dat zich kandidaat stelt, wordt gemeenschappelijk en hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aanbestedende overheid.”

De aankondiging leert ook:

“De dialoog wil de technische, juridische en financiële middelen en modi operandi van het project definiëren.

Het verloop ervan en de opeenvolgende selectiemodaliteiten van de gekozen oplossingen worden eveneens verduidelijkt in het beschrijvende document. Alle aspecten van de overeenkomst kunnen besproken worden, met uitzondering van de essentiële kenmerken van het project.”

9.3. Het reeds aangehaalde punt I.11 van de dialooggids stelt dat elk lid van een consortium ten opzichte van de aanbestedende overheid “gemeenschappelijk en hoofdelijk aansprakelijk” is voor de offerte die zijn consortium indient.

Punt I.13 van de dialooggids vereist van de deelnemer die de uitvoering van de opdracht toevertrouwt aan een projectvennootschap onder meer dat hij “aan zijn Tweede Voorstel/Definitieve Offerte [toevoegt,] een waarborg voor de financiële verplichtingen van de Projectvennootschap verbonden aan de uitvoering van deze opdracht door alle leden van het consortium, en dit hoofdelijk of middels een bankgarantie op eerste verzoek”.

9.4. In de brief van 17 september 2015 brengt de verwerende partij verzoeksters in herinnering “dat een van de hoofdpunten met betrekking tot NEO 2 Project is dat het consortium hoofdelijk aansprakelijk blijft ten aanzien van de overheid”, merkt zij op dat “als 100% van de aandelen van SPV1 gehouden worden door een andere partij dan het consortium, is het onduidelijk of de overheid kan blijven een voordeel halen uit de hoofdelijke aansprakelijkheidsmechanisme zoals voorzien onder punt I.13 van de Dialooggids” en wijst zij op de noodzaak om verenigbaar te zijn met punt I.13 van de dialooggids.

9.5. Het eveneens geciteerde punt I.3.6 van de oriënteringsgids kwalificeert de hoofdelijke aansprakelijkheid van de deelgenoten van de deelnemer expliciet als een “essentieel” beginsel waarop het contractueel begrip van de opdracht berust. Het verduidelijkt enkel – in antwoord op de vragen en opmerkingen van de deelnemers tijdens de eerste dialoofase – hoe die hoofdelijkheid moet worden opgevat – “volledig” tijdens de bouwfase, zowel voor het congrescentrum als voor het hotel en, “voor het Hotel”, op “voorwaarden overeen te komen”, tijdens een “redelijke exploitatieperiode” daarna.

Punt I.8 van de oriënteringsgids herneemt het principe en verwijst nogmaals naar “de beginselen vermeld in het hogervermelde punt I.3.6”.

9.6. In tegenstelling tot wat verzoeksters betogen, zaaien ook de antwoorden van de verwerende partij op de haar gestelde vragen op het eerste gezicht geen twijfel en verwarring over het essentieel karakter van de

aansprakelijkheid, integendeel. Ze bevestigen net het beginsel van de enige en ondeelbare solidariteit tussen de leden van het consortium:

- antwoord op vraag 2: “De leden van de Kandidaat blijven solidair aansprakelijk gedurende een redelijke termijn van uitbating, bepaald door de Heads of Terms, en volgens de overeen te komen modaliteiten, hierin inbegrepen in geval van overdracht van het geheel of een deel van de rechten met betrekking tot het Hotel en/of zijn uitbating of in geval van overdracht van aandelen van de projectvennootschap aan wie de bouw en/of de exploitatie en/of het beheer van het Hotel zal zijn toevertrouwd. Er wordt eveneens verwezen naar het punt ‘hoofdelijkheid’ in de Heads of Terms in het geval van een projectvennootschap gecreëerd zou worden, eventuele veranderingen in de uitgeoefende controle over de SPV Hotel en/of de overdracht van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract en/of de overdracht van het gebouw van het Hotel. De Aanbestedende overheid vestigt de aandacht van de Kandidaten op dat het beginsel van solidariteit in geval van eventuele verandering in controle over de SPV Hotel en/of de overdracht van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract en/of de overdracht van het gebouw van het Hotel, desgevallend, cumulatief en niet alternatief of exclusief ten opzicht van elkaar zijn”;

- antwoord op vraag 7: “De Aanbestedende overheid wil een duurzaam engagement bekomen van de leden van de Gegadigde met het oog op een goede realisatie van de gehele opdracht, derhalve dat het de leden zijn – desgevallend, met de steun van derde entiteiten – die de kwalitatieve selectie van de Inschrijver heeft mogelijk gemaakt. De modaliteiten van deze garantie zijn gepreciseerd in het punt I.3.6 van de administratieve gids en in het kader van de Bijlages I en II van de Oriënteringsgids, teneinde rekening te houden met de economische realiteit van de opdracht en de specificiteiten van elk onderwerp van deze opdracht. Het principe zelf van de solidariteit, dat vanaf de aankondiging van de opdracht en de Dialooggids is neergelegd, moet evenwel behouden blijven”;

- antwoord op vraag 8: “De solidariteit die van de leden van de Inschrijver wordt verwacht in de constructiefase is ‘totaal’. Dit wil zeggen dat ze, op ondeelbare wijze, zowel de realisatie van het project van het Congrescentrum als de realisatie van het project van het Hotel dekt. Op het einde van de constructiefase –

gekenmerkt door de aflevering van het Certificaat van Beschikbaarheid in het kader van het DBFM-contract –, betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid die verwacht wordt van de leden van de Inschrijver, zoals geëxpliciteerd in het punt I.3.6 van de administratieve gids, enkel de goede exploitatie van het Hotel onder de overeengekomen voorwaarden in het kader van het contract Hotel. Dit zonder afbreuk te doen aan de garantiemechanismen van de financiële engagements van de Projectvennootschap(pen) bedoeld in punt I.8 van het eerste hoofdstuk van de Oriënteringsgids, evenals de andere vernoemde regels door de Ontwerpovereenkomst en de Heads of Terms”;

- antwoord op vraag 18: “Deze hypothese [van oprichting van twee projectvennootschappen] is expliciet beoogd, zowel door de gegeven definitie aan ‘Projectvennootschap’ in het punt I.1.2 van de Oriënteringsgids, dan ook in het punt van I.8 van dezelfde gids. Dit wijzigt echter niets aan de draagwijdte van de hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid in hoofde van de leden van de Kandidaat, zoals uiteengezet en gepreciseerd in het punt I.3.6 van de Oriënteringsgids en haar bijlages I en 2”;

- antwoord op vraag 22: “De solidaire garantie (van de leden van de Kandidaat en, desgevallend, van de betrokken derde entiteiten) bedoeld in punt III.4 betreft het ter beschikking stellen aan elke opgerichte SPV met het oog op de realisatie van de opdracht, van de capaciteiten en de nodige middelen voor het deel van de opdracht die aan haar is toevertrouwd, in het bijzonder, de garantie van de financiële engagements van de Projectvennootschap ten voordele van de Aanbestedende overheid. Deze interpretatie is dus correct in het geval van de oprichting van twee onderscheiden Projectvennootschappen, maar stelt de enige en ondeelbare solidariteit tussen de leden van het consortium niet in vraag voor de fase van constructie van de twee objecten van de opdracht, wat ook de juridische constructie is voor deze constructie”;

- antwoord op vraag 163: “De aanbestedende overheid benadrukt dat de identiteit van een privé investeerder die reeds gecommuniceerd werd die, hetzij een impact heeft op de voldoening aan de kwalitatieve selectiecriteria, hetzij een invloed heeft op het klassement van de Voorstellen in een vroegere fase van de procedure, niet gewijzigd mag worden zonder het voorafgaande akkoord van de Aanbestedende

overheid met het oog op de neerlegging van de definitieve offerte. Er wordt hieromtrent verwezen naar de punten I.11 en II.16 van de Dialooggids”.

10. Voor zover het middelonderdeel uitgaat van de premisse dat de vereiste inzake de vorm waaronder de leden van het consortium zich solidair en hoofdelijk moeten verbinden een voorschrift is waarover twijfel bestaat, mist het ernst. Het beroep op artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek is om die reden hoe dan ook niet pertinent, daargelaten of die bepaling van toepassing zou kunnen zijn.

Bovendien volgt uit de *sub 9* gemaakte vaststellingen *prima facie* dat het voorschrift dat de leden van het consortium zich moeten verbinden tot de hoofdelijke aansprakelijkheid zowel voor de realisatie van de bouw van het congrescentrum als het hotel een essentiële voorwaarde van de opdracht vormt.

De omstandigheid dat de naleving van het beginsel niet uitdrukkelijk is voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid van de voorstellen doet op het eerste gezicht niet anders besluiten.

11. Voorts overtuigen verzoeksters niet dat slechts aan dit essentieel voorschrift voldaan moet zijn op het ogenblik van het indienen van de offerte. Hun argumentatie steunt op een lezing van de aankondiging en de beschrijvende documenten die de Raad van State vooralsnog niet kan bijvallen.

Punt I.13 van de dialooggids laat de deelnemers toe de juridische vorm te kiezen waaronder zijn leden zich solidair en hoofdelijk verbinden tot de uitvoering van de opdracht “gericht op een behoorlijke verwezenlijking van het project volgens de na te leven voorwaarden die in de loop van de dialoog worden vastgesteld”. De aan dialoog onderworpen “na te leven voorwaarden” slaat terug, zo lijkt, op de “behoorlijke verwezenlijking van het project” en niet, zoals verzoeksters lezen, op de “juridische vorm waaronder zijn leden zich [...] verbinden”. Echter zelfs indien verzoeksters’ lezing van dit artikel correct zou zijn, dan lijkt die zinsnede te refereren aan het gegeven dat de aanbestedende overheid

nog moest kiezen tussen de zogenaamde “DB”, “DBF” of “DBFM” scenario’s voor de opdracht, wat een invloed heeft op de contractuele constructie. Hoe dan ook blijft overeind dat op het ogenblik waarop verzoeksters hun tweede voorstel indienen, de oriënteringsgids en de antwoorden en verduidelijkingen van de verwerende partij geen ruimte meer laten tot twijfel.

De opmerking van verzoeksters dat een aanpak-op-maat twee individuele en opgesplitste projecten verdient, spreekt niet tegen dat de leden van het consortium zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de goede uitvoering van dit maatwerk. De verwerende partij beaamt in een van haar antwoorden (antwoord 18) overigens dat werken met twee projectvennootschappen denkbaar is, maar zij onderstreept dadelijk het belang van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel, stellende dat dit “niets [wijzigt] aan de draagwijdte van de hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid in hoofde van de leden van de Kandidaat, zoals uiteengezet en gepreciseerd in het punt I.3.6 van de Oriënteringsgids”. Ook punt I.8 van de oriënteringsgids refereert aan dit punt I.3.6. De goedkeuring van het eerste voorstel impliceerde, anders dan verzoeksters betogen, geenszins dat over deze eis een dialoogvoering tot de mogelijkheden behoorde.

De verwijzing, op de terechtzitting, naar de sanctie op bladzijde 31-32 van de dialooggids is laattijdig en lijkt hoe dan ook niet ter zake, want te betrekken op de vervanging van het deelnemend consortium door een projectvennootschap zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de aanbestedende overheid en niet op de draagkrachtvereiste zelf.

De eveneens slechts op de terechtzitting geformuleerde opmerking over de bankgarantie die als alternatief maar mogelijk is op het ogenblik van een definitieve offerte, overtuigt evenmin. De passus waaraan verzoeksters refereren vermeldt zowel het tweede voorstel als de definitieve offerte en kan zinvol zo gelezen worden dat de bankgarantie een alternatief wordt voor de aansprakelijkheidsverbintenis op een later ogenblik, namelijk bij de definitieve offerte. Deze passus lijkt bijgevolg geenszins de overdaad van andere documenten

tegen te spreken, die aangeven dat de juridische verbintenis moet uitgaan van de leden van het consortium en bevestigd zijn tijdens de dialoofase.

12. Uit het als vertrouwelijk stuk neergelegde tweede voorstel van verzoeksters blijkt in de huidige stand van de procedure dat de in het eerste voorstel van verzoeksters bepaalde contractuele structuur wezenlijk verschilt van die bepaald in het tweede voorstel.

In het eerste voorstel bevat de contractuele structuur langs de zijde van het hotel drie contractuele niveaus en langs de zijde van het congrescentrum twee of drie contractuele niveaus. Voor de beide onderdelen van de opdracht wordt op niveau 1 ('level 1') als rechtstreekse contractant van de verwerende partij bepaald de SPV (projectvennootschap) 1, samengesteld uit de nv CEI-De Meyer, nv Galère en de Ghelamco Group. Door verzoeksters werd overeenkomstig het gevraagde in de aankondiging verklaard dat, voor wat dit niveau 1 betreft, "de juridische structuur is gebaseerd op het principe dat gedurende de hele duur van het project, Vennootschap NEO steeds 1 contactpunt heeft dat de volledige verantwoordelijkheid draagt om het project af te leveren volgens de verwachtingen van Vennootschap NEO. Dit zal SPV1 zijn". Op het tweede niveau zou de Congrescentrum-SPV gehouden worden door BAM PPP en de Hotel-SPV zou in handen zijn van Ghelamco Group.

In het tweede voorstel verdwijnt het initiële eerste niveau en verschijnen twee SPV's als de nieuwe rechtstreekse contractanten van de verwerende partij. Nog volgens de gegevens verstrekt in dit tweede voorstel zullen de oorspronkelijke leden van het consortium, zijnde nv BAM Contractors en nv Galère, op het ogenblik van de gunning van de opdracht, elk slechts een verwaarloosbaar percentage van de aandelen houden in deze SPV's. Vanaf de sluiting van de overeenkomst zullen zij verdwijnen uit de aandeelhoudersstructuur.

13. Doordat in het tweede voorstel het oorspronkelijke consortium de uitvoering van de opdracht toevertrouwt aan twee SPV's, de ene verantwoordelijk voor het congrescentrum en de andere verantwoordelijk voor het hotel, en het daarin slechts een marginale participatie behoudt die bovendien een einde neemt vanaf de sluiting van de overeenkomst, zullen de twee SPV's in de uitvoeringsfase volledig in handen zijn van derde vennootschappen die de verwerende partij niet heeft geselecteerd.

Bovendien nemen de twee nieuwe SPV's enkel aansprakelijkheid op voor één aspect van de opdracht.

Het bestreden besluit leidt hieruit terecht af, zo lijkt, dat “dit contractueel proces veronderstelt dat de twee leden van consortium A die door de Vennootschap geselecteerd werden zich niet ten aanzien van de Vennootschap verbinden om de opdracht uit te voeren, hun uiterst geringe participatie in de twee SPV's kan deze vaststelling niet verhullen, nu deze participatie uitdrukkelijk beperkt is tot het stadium van de gunning van de opdracht”.

14. Het bestreden besluit wijst er bovendien op – andermaal terecht, zo lijkt, gelet op de neergelegde stukken – dat de Koninklijke BAM Groep, die het consortium op het ogenblik van de selectie toeliet om met toepassing van artikel 74 van het KB Plaatsing aan te tonen dat werd voldaan aan de criteria voor de economische en financiële draagkracht, geen enkele participatie zal bezitten in de twee SPV's die de opdracht zullen uitvoeren, noch de draagkracht van het project voort verzekert.

15. Het betoog van verzoeksters dat deze ondersteuning door de leden van het consortium of de ondersteunende derde entiteit in het tweede voorstel wel overeind gebleven zou zijn, wordt vooralsnog niet bijgevallen. Een verklaring dat de deelnemer en de Koninklijke BAM Groep ernaar streven (s'efforceront) dat de projectvennootschappen de financiële engagements aangaan als dienstverlener toont alleszins niet het blijvende engagement aan van de

eerstgenoemden om zelf de hoofdelijke aansprakelijkheid te accepteren of te continueren. De bijkomende verklaring dat de “zogeheten” (*so-called*) hoofdelijke aansprakelijkheid onaanvaardbaar (*not acceptable*) is voor de deelnemer doet zelfs van het tegendeel blijken.

16. De verwerende partij mocht *prima facie* dan ook vaststellen dat de weigering door verzoeksters om in hun contractueel project het beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid op te nemen, bevestiging vindt in de uitdrukkelijke afwijzing door de leden van het consortium van de gevraagde hoofdelijke aansprakelijkheid die volgens hen noch conform de heersende marktpraktijken, noch financierbaar zou zijn en in het niet voorliggen van een resultaatsverbintenis in hoofde van de leden van het consortium of de Koninklijke BAM Groep om de financiële verplichtingen van de SPV's te waarborgen.

17. Verzoeksters hebben de vaststellingen van de verwerende partij in het bestreden besluit dat “de leden van het consortium A het principe van de aansprakelijkheid, ten aanzien van de Vennootschap, voor de verplichtingen van de SPV's, en a fortiori, het principe van de hoofdelijkheid, zoals vastgelegd in voornoemd artikel I.3.6., niet aanvaarden”, dat “zij het essentiële beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid in alle stadia van de uitvoering van de opdracht verwerpen, het is te zeggen gedurende de constructiefase van het congrescentrum en het hotel en tijdens de redelijke exploitatieperiode van het hotel” en dat “de leden van het consortium A in hun contractueel project geen enkele clause opnemen die een band creëert tussen de verbintenissen met betrekking tot het hotel en degene met betrekking tot het congrescentrum [hetgeen] in werkelijkheid neerkomt op het opheffen van de uniciteit van de opdracht die betrekking heeft op de geïntegreerde realisatie, en niet gescheiden, van een congrescentrum en een hotel” in de huidige stand van de procedure niet overtuigend kunnen weerleggen.

De verwerende partij mocht op het eerste gezicht uit die vaststellingen regelmatig afleiden dat het tweede voorstel van het consortium

strijdt met het als essentieel bestempeld beginsel van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

18. In het tweede middelonderdeel van het tweede middel tonen verzoeksters niet aan dat de verwerende partij het tweede voorstel niet onregelmatig mocht verklaren.

In zoverre verzoeksters in ondergeschikte orde waarschuwen dat een en ander impliceert dat de overige twee deelnemers een tweede voorstel hebben ingediend dat wel voldoet aan de gevraagde juridische vorm, zij vastgesteld dat door de verwerende partij naar luid van de bestreden beslissing hierover de volgende vaststelling is gedaan:

“Dat meer in het bijzonder wat betreft de eis van de hoofdelijke aansprakelijkheid, deze, in tegenstelling tot wat consortium A beweert, noch onverenigbaar met de heersende marktpraktijken, noch niet-financierbaar lijkt te zijn, aangezien de andere Deelnemers dit wel opnemen in hun tweede Voorstel; Dat dit bovendien niet beantwoordt aan de behoeften van de Vennootschap, en een opheffing van dit principe –uitdrukkelijk als essentieel aangeduid – wegens de door het consortium A ingeroepen redenen, niet overwogen kan worden, op straffe van vervalsing van de mededinging en bevoordeling van het consortium, en dit ten nadele van de twee andere Deelnemers die wel aanvaarden om hiermee rekening te houden in hun contractueel project.”

Op de terechtzitting dringen verzoeksters aan op een inhoudelijk onderzoek hiervan door de Raad van State. Zij geven op die manier echter een nieuwe, laattijdige en onontvankelijke invulling aan het middelonderdeel.

19. Het tweede onderdeel van het tweede middel is niet ernstig.

B. Eerste middel

Uiteenzetting van het middel

20. Een eerste middel wordt geput uit de schending van artikel 27 van de overheidsopdrachtenwet van 5 juni 2006, van de artikelen 111, § 3, en 113, § 2, van het KB Plaatsing, gelezen samen met “de Dialooggids (artikel I.7, afdeling II en artikel II.11) en de Oriënteringsgids (artikel I.5, afdeling II en artikel II.4)” en van de materiële motiveringsplicht, het beginsel *patere legem quam ipse fecisti*, het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel,

“dit doordat de verwerende partij tijdens de Tweede Dialoofase en zonder enige voorafgaande dialoogvoering het Tweede Voorstel vanwege verzoekende partij als onregelmatig verklaart en uitsluit.

Terwijl de ratio legis en de essentie van een concurrentiegericht dialoog en de aard van een Voorstel de verwerende partij gebieden tot het voeren van een dialoog omtrent het door een deelnemer ingediend Tweede Voorstel tot op het moment dat de verwerende partij kan bepalen welke oplossing of oplossingen aan haar behoeften en eisen kan of kunnen voldoen, zijnde de sluiting van de dialoog.”

In wezen voeren verzoeksters aan dat zowel de essentie van de concurrentiegericht dialoog als de dialooggids en de oriënteringsgids zich in beginsel verzetten tegen elke vorm van afbreken van de dialoogvoering vooraleer de oplossingen zijn gevonden die het best beantwoorden aan de behoeften en eisen van de aanbestedende overheid en al helemaal in de fase nadat de eerste dialoofase is afgerond.

Zich bewust van de ingrijpende impact van een uitsluiting van een deelnemer is in de opdrachtdocumenten gepreciseerd dat uitsluiting van een deelnemer slechts in zeer beperkte mate mogelijk is, namelijk indien cumulatief (i) het tweede voorstel een essentiële wijziging inhoudt, (ii) de verwerende partij daarop een verzoek tot de deelnemer richt tot schrapping van deze wijziging en indiening van een aangepast tweede voorstel en (iii) de deelnemer aan dit verzoek geen gunstig gevolg geeft.

‡BIHQKDGDJ-BCGAHAV‡

Verzoeksters stellen vast dat de verwerende partij niet aan deze voorwaarde heeft voldaan.

Niet alleen miskent de verwerende partij aldus flagrant de door haar opgestelde opdrachtdocumenten maar bovendien weigert zij aan verzoeksters een procedurestap aan te bieden die aan alle deelnemers ter beschikking staat om tot de schrapping van deze wijziging over te gaan. Dit maakt een schending uit van het gelijkheidsbeginsel.

Tot slot maken zij nog de bedenking dat een voorstel in het kader van een dialoogronde niet eenzelfde draagwijdte heeft als een offerte. Het niet aangaan van een dialoog maar het onmiddellijk overgaan tot definitieve uitsluiting druist in tegen de draagwijdte van een voorstel en het doel van de dialoog.

Beoordeling

21. Het beschrijvend document lijkt het indienen van meerdere voorstellen door eenzelfde deelnemer niet uit te sluiten en laat expliciet toe om suggesties (eerste voorstel) of aanvullingen (tweede voorstel) te formuleren. Verzoeksters zijn evenwel niet zo tewerk gegaan, zij hebben één tweede voorstel ingediend met een aangepaste contractuele structuur.

Dat tweede voorstel echter, stuit op het zo-even besproken euvel met betrekking tot de juridische verbintenissen van de deelnemers aan het consortium.

De formulering ervan, als gezien, heeft dialogeren niet ingerekend. Hoofdelijke aansprakelijkheid is niet ‘bankable’, is onaanvaardbaar.

22. Het gegeven dat de gunningswijze die van de concurrentiedialoog is, lijkt er niet aan in de weg te staan dat een aanbestedende overheid, zelfs in de stadia voorafgaand aan de indiening van de offertes, zo een

voorstel zou kunnen afwijzen, wanneer dat voorstel essentiële beginselen van de betrokken opdracht opzij schuift en zo de gelijkheid tussen de deelnemers in het gedrang brengt.

Uit het stappenplan inzake het verloop van de dialoog volgens punt I.7 van de dialooggids en punt I.5 van de oriënteringsgids lijkt voor de aanbestedende overheid, anders dan verzoeksters betogen, geen algemene verplichting te kunnen worden afgeleid om de sluiting van de dialoog af te wachten alvorens een voorstel dat substantieel onregelmatig is bevonden – en dit daarenboven slechts ná de uitnodiging om deel te nemen aan de tweede dialoofase is geworden – te mogen weren.

Het verwijt van de verwerende partij aan de verzoekende partijen in dit verband dat zij het begrip “verwijdering van de ontoereikende Voorstellen” – punt 6 van het onder punt I.7 van de dialooggids geschetste verloop van de dialoog – ten onrechte lijken te vereenzelvigen met de hun ten laste gelegde substantiële onregelmatigheid van het voorstel, kan worden bijgevallen. Als ontoereikend worden overeenkomstig punt II.7.3 van de dialooggids aangemerkt, “de voorstellen die op grond van deze (gunnings)criteria geen gemiddelde score bereiken van 50% of meer van de hieraan toegekende punten”. Ontoereikende voorstellen moeten *prima facie* derhalve worden begrepen als voorstellen die niet zijn behept met een onregelmatigheid, maar niet voldoen aan de verwachtingen van de aanbestedende overheid.

Overigens moet worden opgemerkt dat beide documenten op andere plaatsen de uitsluiting van een deelnemer mogelijk lijken te maken indien aan zekere voorwaarden niet is voldaan, bijvoorbeeld in punt II.7.1 van de dialooggids met betrekking tot de volledigheid en vormelijke regelmatigheid van de voorstellen.

23. Hiervóór is reeds voorlopig aangenomen dat het falen dat kleeft aan het tweede voorstel van verzoeksters een essentieel element betreft, namelijk de selectievoorwaarden betreffend.

De verwerende partij lijkt dan ook terecht vast te stellen dat het “onnuttig” is om het tweede voorstel nog te bespreken “indien de substantiële onregelmatigheden [...] niet meer op wettelijke wijze kunnen worden gecorrigeerd en die dus op het einde van de tweede Fase van de dialoog, in elk geval en los van de inhoud van de komende besprekingen, geweerd moeten worden”.

Verzoeksters weren zich tegen de stelling dat de onregelmatigheid niet meer kan worden gecorrigeerd, door een beroep te willen doen op de mogelijkheid, vermeld in het beschrijvende document, om al dialogerend het voorstel aan te passen.

Echter is reeds opgemerkt dat hun tweede voorstel inzake de aansprakelijkheid aldus is geformuleerd dat verzoeksters zelf de dialoog erover uitsluiten. Voorts lijken verzoeksters zich vergeefs te beroepen op de punten II.11 van de dialooggids en II.4 van de oriënteringsgids die bepalen onder welke voorwaarden essentiële wijzigingen naar aanleiding van de uitwerking van de tweede voorstellen aanleiding kunnen geven tot uitsluiting van de deelnemer. Luidens die punten “verzoekt de Aanbestedende Overheid de Deelnemer deze wijziging te schrappen en een Tweede Voorstel zonder de wijziging voor te leggen”. In de voorliggende zaak is echter geen sprake van het “schrappen” van een wijziging. Enkel een fundamenteel nieuw voorstel zou een basis kunnen vormen voor een dialoog.

De door verzoeksters aangevoerde bepalingen van het beschrijvend document zijn ondergebracht in deel II van de documenten over het verloop van de dialoog. Ze lijken de hiervoor besproken algemene bepalingen, namelijk de punten I.11 en I.13 van de dialooggids en punt I.3.6. van de oriënteringsgids, onverlet te laten en lijken in verband gebracht te moeten worden,

veeleer, met wijzigingen die zouden aanleiding geven tot “ontoereikende voorstellen”. Een andere lezing, namelijk die welke verzoeksters verdedigen, lijkt onverenigbaar met het Unierechtelijk gelijkheidsbeginsel, artikel 5 van de overheidsopdrachtenwetgeving en artikel 111, § 4 en 113, § 2, derde lid, KB Plaatsing.

Terecht dan ook, zo lijkt, oordeelt de verwerende partij dat dit strijdig moet worden geacht met de gelijke behandeling van alle deelnemers en om die reden niet meer “op wettelijke wijze” kan worden gecorrigeerd:

“Dat het principe van gelijkheid en non-discriminatie de Vennootschap verbiedt het consortium A te vragen om een nieuw Voorstel in te dienen dat in overeenstemming zou zijn met de essentiële beginselen van de opdracht. Dat een dergelijke houding er inderdaad op neer zou komen dat consortium A de mogelijkheid krijgt om te verhelpen aan substantiële onregelmatigheden en om een volledig nieuw contractueel project voor te stellen in vergelijking met wat het consortium had voorzien in zijn tweede Voorstel; dat dit dus als gevolg zou hebben dat tijdens de gunning een deelnemer, die in tegenstelling tot de twee andere, duidelijk geweigerd heeft om de eisen van de aanbestedende overheid, na te leven terug zou worden ‘opgevist’ en dat het de deelnemer zou worden toegestaan om een voorstel te regulariseren dat niet regelmatig was op punten die uitdrukkelijk als essentieel werden bestempeld.”

24. Het eerste middel is niet ernstig.

C. Eerste onderdeel van het tweede middel

Uiteenzetting van het middelonderdeel

25. Een tweede middel, eerste middelonderdeel, is geput uit de schending van artikel 27 van de overheidsopdrachtenwet, artikel 111, § 1, KB Plaatsing, de punten I.11 en I.13 van de dialooggids, punt I.8 van de oriënteringsgids, de materiële motiveringsplicht, het beginsel *patere legem quam ipse fecisti*, het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het proportionaliteitsbeginsel, het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel,

“doordat, eerste onderdeel, de verwerende partij de door de verzoekende partij in haar Tweede Voorstel voorgestelde aanvulling met operatoren die beschikken over specifieke vaardigheden voor de verwezenlijking van bepaalde delen van de Opdracht verkeerdelijk interpreteert als en gelijkstelt met een ongeoorloofde wijziging van de samenstelling van de verzoekende partij, waarop verzoekende partij wordt uitgesloten.

Terwijl het Tweede Voorstel vanwege de verzoekende partij een loutere, geoorloofde aanvulling van de verzoekende partij in de uitvoeringsfase vooropstelt.”

26. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op wat volgt:

“Alvorens die twee onderdelen te weerleggen, wenst verwerende partij te benadrukken dat de bestreden beslissing gesteund is op twee motieven die op gelijke voet staan. Eén van de beide bekritiseerde motieven volstaat om de wettigheid van de bestreden beslissing te onderbouwen. Bijgevolg kan de bestreden beslissing slechts geschorst worden indien de beide motieven onwettig zouden blijken. Met andere woorden moet worden vastgesteld dat de ontvankelijkheid van elk van de twee onderdelen verbonden is met de gegrondheid van het andere onderdeel. Het gebeurlijk ernstig bevinden van één onderdeel volstaat niet om de bestreden beslissing te schorsen (RvS. arrest n° 234.588, d.d 28 april 2016).”

27. Deze opmerking is op de terechtzitting door verzoeksters onbeantwoord gebleven.

Beoordeling

28. De Raad van State valt de verwerende partij bij. De kritiek van verzoeksters lijkt gericht tegen een overtollig motief. Zelfs indien ze gegrond – thans: ernstig – ware, zou ze niet tot de nietigverklaring – thans: schorsing – kunnen leiden, gelet op de – voorlopige – verwerping van het tweede middelonderdeel, dat gericht is tegen een motief dat autonoom de wettigheid van de bestreden beslissing kan schragen.

29. Het middelonderdeel is om die reden niet ernstig.

D. Derde middel

Uiteenzetting van het middel

30. Een derde middel is afgeleid uit de schending van artikel 18, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 ‘op het gebruik van de talen in bestuurszaken’ (hierna: bestuurstaalwet),

“doordat de verwerende partij de bestreden beslissing louter in het Frans aan de verzoekende partij ter kennis bracht.

Terwijl de verwerende partij de bestreden beslissing aan de verzoekende partij ter kennis diende te brengen in het Frans én in het Nederlands.”

Verzoeksters lichten toe dat “de bestreden beslissing aanvankelijk een stuk in binnendienst uitmaakte die echter door de bekendmakingsplicht gekwalificeerd moet worden als zijnde een mededeling aan het publiek [zodat de bestreden beslissing krachtens artikel 18, eerste lid] zowel in het Nederlands als in het Frans diende opgesteld te zijn”.

Beoordeling

31. Artikel 18, eerste lid, van de bestuurstaalwet luidt:

“De plaatselijke diensten, die in Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn, stellen de berichten, mededelingen en formulieren die voor het publiek bestemd zijn in het Nederlands en in het Frans.”

32. In de nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij (voetnoten weggelaten):

“Dit [artikel] omvat de informatie die een plaatselijke dienst verstrekt of moet verstrekken aan het publiek, d.w.z. aan niet geïndividualiseerde personen.

Dit is zeker niet het geval voor de beslissing waarbij verwerende partij het Tweede Voorstel van verzoekende partijen onregelmatig verklaart en verzoekende partijen bijgevolg uit de concurrentiedialoog uitsluit. Verzoekende partijen zijn immers wel degelijk individualiseerbaar en verwerende partij weet wie haar gesprekspartner is. Dergelijke beslissing is

ook enkel bedoeld om medegedeeld te worden aan de onregelmatige deelnemer (hier verzoekende Partijen). Bijgevolg is niet artikel 18, [...] van toepassing, [...]. Deze benadering werd door Uw Raad reeds toegepast met betrekking tot gelijkaardige beslissingen.”

De verwerende partij verwijst naar arrest nr. 59.456 van 30 april 1996 en arrest nr. 180.177 van 28 februari 2008.

33. In de huidige stand van de rechtspleging valt de Raad van State het aangehaalde verweer bij. Bijkomend mag nog worden verwezen naar de arresten nrs. 224.381 van 19 juli 2013, 225.884 van 18 december 2013 en 230.117 van 5 februari 2015, in dezelfde zin.

Verzoeksters lijken ten onrechte te verwijzen naar arrest nr. 180.177 van 28 februari 2008. In dit arrest kwalificeert de Raad immers de aanzegging van een gemotiveerde toewijzingsbeslissing aan een inschrijver evenmin als een mededeling aan het publiek.

34. De onregelmatigverklaring van verzoeksters lijkt geen mededeling aan het publiek, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de bestuursaalwet.

Het middel, dat uitgaat van de tegenovergestelde opvatting, is niet ernstig.

VII. Rechtsplegingsvergoeding

35. De rechtsplegingsvergoeding die de Raad van State kan toekennen is luidens artikel 30/1, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Het door de verwerende partij aan verzoeksters verweten “eigen foutieve gedrag” dat “de onregelmatigheid heeft veroorzaakt” volstaat niet om de

door haar gevraagde hogere tegemoetkoming in deze kosten en honoraria te verantwoorden.

Met een inleidend verzoekschrift van 27 bladzijden kan de verwijzing door de verwerende partij naar de “omvang van hun verzoekschrift” evenmin tot een verhoging van het basisbedrag overtuigen.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt de vordering.

2. De verzoekende partijen worden verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 400 euro, elk voor de helft en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 18 juli 2016, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer, samengesteld uit:

Geert Van Haegendoren,	kamervoorzitter,
bijgestaan door	
Joris Casneuf,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Joris Casneuf

Geert Van Haegendoren